

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1903/2565

พนักงานอัยการจังหวัด  
นาย ธ.

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ วรรคสี่, มาตรา 172 ตรี วรรคสาม

แม้ผู้เสียหายไม่ได้เบิกความถึงการกระทำชำเราของจำเลยอีกกระทงหนึ่ง แต่เมื่อศาลชั้นต้นจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหายซึ่งพนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 133 ทวิ วรรคสี่ ให้คู่ความฟังแล้ว จึงต้องถือสื่อภาพและเสียงดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของผู้เสียหายในชั้นพิจารณาของศาลตาม ป.วิ.อ. มาตรา 172 ตรี วรรคสาม เมื่อสื่อภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหายมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำชำเราอีกกระทงหนึ่งนั้น ต้องถือว่าผู้เสียหายเบิกความถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในชั้นพิจารณาแล้ว

---

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1, 91, 277, 279, 285, 285/1

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง, 279 วรรคสาม ประกอบมาตรา 285 การกระทำของจำเลยเป็นความ

ผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวล  
กฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งอยู่ภายใต้  
อำนาจด้วยประการอื่นใด โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และฐานกระทำอนาจาร  
แก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด โดยเด็กนั้นจะ  
ยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถ  
ขัดขืนได้ตามฟ้องซึ่งได้กระทำเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม  
2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562  
และวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลากลางวัน เป็นการกระทำความผิดเป็นความผิดต่อ  
กฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง  
ประกอบมาตรา 285 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมาย  
อาญา มาตรา 90 จำคุกกระทงละ 9 ปี 4 เดือน รวม 6 กระทง เป็นจำคุก 54 ปี 24  
เดือน ฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการ  
อื่นใด โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ใน  
ภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามฟ้องซึ่งได้กระทำเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา  
กลางคืนก่อนเที่ยง จำคุก 1 ปี 4 เดือน รวมจำคุก 55 ปี 28 เดือน แต่เมื่อรวมโทษ  
ทุกกระทงแล้ว คงจำคุก 50 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3)

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้  
ว่า เด็กหญิง อ. ผู้เสียหาย เกิดวันที่ 8 มกราคม 2552 ขณะเกิดเหตุอายุ 10 ปีเศษ  
เป็นบุตรของนางสาว น. และนาย พ. นางสาว น. และนาย พ. หย่ากันเมื่อปี 2551

แล้วนางสาว น. เป็นผู้ปกครองดูแลผู้เสียหาย ปี 2556 นางสาว น. อยู่กินฉันสามีภริยากับจำเลยที่บ้านเกิดเหตุ โดยนางสาว น. พาผู้เสียหายมาอยู่ร่วมบ้านเดียวกันด้วยวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาว น. พาผู้เสียหายไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรให้ดำเนินคดีแก่จำเลย พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้เสียหายไปให้แพทย์โรงพยาบาลตรวจร่างกาย แพทย์หญิง อ. ตรวจร่างกายผู้เสียหายพบบาดแผลถลอกที่ต้นขาข้างอวัยวะเพศ บาดแผลฟกช้ำที่ปุ่มกระสัน รอยแดงที่แคมเล็ก รอยฉีกขาดเก่าของฝีเย็บที่ตำแหน่ง 8 นาฬิกา ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบอสุจิ ไม่พบสารประกอบของน้ำอสุจิโดยวิธีแอซิดฟอสฟาเตส (Acid phosphatase) แล้วลงความเห็น ว่า ผู้เสียหายน่าจะผ่านการร่วมประเวณี วันที่ 15 สิงหาคม 2562 และวันที่ 13 กันยายน 2562 เจ้าพนักงานตำรวจแจ้งข้อหาและแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแก่จำเลย ว่า กระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม อันเป็นการกระทำแก่ผู้อยู่ในความปกครองหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด และกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ อันเป็นการกระทำแก่ผู้อยู่ในความปกครองหรือผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด จำเลยให้การปฏิเสธ ชั้นสอบสวน พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาจำเลยเช่นเดียวกับชั้นแจ้งข้อกล่าวหา จำเลยให้การปฏิเสธ สำหรับความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 1 ปี 4 เดือน จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน โดยยังคงให้ลงโทษจำคุกจำเลยในความผิดฐานนี้ไม่เกินห้าปี จึงต้องห้ามมิให้จำเลยปฏิบัติหน้าที่จริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่ง จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีพยานบุคคลอื่นที่รู้เห็นนอกจากผู้เสียหายซึ่งเป็นเด็ก แม้มารดาผู้เสียหายอยู่บ้านเดียวกัน นอนด้วยกัน ยังไม่ทราบเรื่อง เพิ่งทราบเมื่อผู้เสียหายเล่าให้ฟัง แพทย์ไม่

พบหลักฐานที่แสดงว่าจำเลยเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนร่วมกระทำประกอบกับจำเลยให้การปฏิเสธตลอดมา พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่น่าจะรับฟังได้ ซึ่งเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 7 ในความผิดฐานดังกล่าว จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง โดยไม่ปรากฏว่าผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์ภาค 7 อนุญาตให้ฎีกาหรืออัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 221 ฎีกาของจำเลยในความผิดฐานนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายแม้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยในความผิดฐานนี้มาด้วย ก็ไม่ทำให้เป็นฎีกาที่ชอบด้วยกฎหมายไปได้ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยเฉพาะความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตามฟ้องข้อ 1.6

คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม และฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามฟ้องข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 และข้อ 1.7 ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายเป็นพยานเบิกความว่า ขณะเกิดเหตุ ผู้เสียหายเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2562 จำวันที่ไม่ได้ หลังจากเลิกเรียนผู้เสียหายกลับถึงบ้านพบจำเลยอยู่ภายในบ้าน แต่ไม่พบนางสาว น. เพราะยังไม่กลับจากทำงาน จำเลยจับผู้เสียหายไปนอนบนเบาะซึ่งเป็นที่นอนแล้วจำเลยถอดกางเกงของผู้เสียหายออก หลังจากนั้นจำเลยถอดกางเกงของตนออกและใช้น้ำมันสำหรับทาผมทาที่อวัยวะเพศของจำเลย แล้วจำเลยสอดใส่อวัยวะเพศของจำเลยเข้ามาในอวัยวะเพศของผู้เสียหาย ชัก

เข้าชักออก เมื่อเสร็จแล้วจำเลยให้เงินผู้เสียหายครั้งละ 100 บาท พร้อมสั่งห้ามมิให้บอกเรื่องที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่น จำเลยกระทำกับผู้เสียหายในลักษณะเดียวกันรวม 5 วัน ต่อมาตอนเช้าวันหนึ่ง ขณะที่นางสาว น. ลูกไปหุงข้าว คงเหลือผู้เสียหายนอนอยู่กับจำเลยเพียงลำพังบนเบาะที่นอน จำเลยใช้มือจับอวัยวะเพศของผู้เสียหาย วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ผู้เสียหายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้นางสาว น. พัง นางสาว น. พาผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และโจทก์มีนางสาว น. เป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา ผู้เสียหายเล่าให้พยานฟังว่า จำเลยจับอวัยวะเพศ จับกัน พยานตกใจจึงไม่ได้ถามรายละเอียด ขณะนั้นจำเลยอยู่ภายในบ้าน แต่ผู้เสียหายเล่าให้ฟังด้วยเสียงเบาจำเลยจึงไม่ได้ยิน พยานพาผู้เสียหายออกจากบ้านไปที่บ้านนาง ณ. น้องสาวพยาน นาง ณ. สอบถามผู้เสียหาย ผู้เสียหายบอกว่าจำเลยจับอวัยวะเพศและจับกัน พยานจึงพาผู้เสียหายไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจ เจ้าพนักงานตำรวจพาผู้เสียหายไปให้แพทย์โรงพยาบาลตรวจร่างกาย นอกจากนี้โจทก์มีพยานตำรวจโท อ. พนักงานสอบสวนเป็นพยานเบิกความว่า เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ขณะพยานปฏิบัติหน้าที่เวรอยู่ที่สถานีตำรวจภูธร นางสาว น. พาผู้เสียหายไปแจ้งความต่อพยานว่า ผู้เสียหายถูกจำเลยซึ่งเป็นบิดาเลี้ยงกระทำชำเรา พยานส่งตัวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล วันที่ 12 สิงหาคม 2562 พยานสอบปากคำนางสาว น. ไว้ วันที่ 13 สิงหาคม 2562 พยานสอบปากคำผู้เสียหายที่สำนักงานอัยการจังหวัด โดยมีพนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาว น. มารดาผู้เสียหายร่วมสอบปากคำด้วย มีการบันทึกภาพและเสียงการสอบปากคำไว้ เห็นว่า แม้โจทก์มีผู้เสียหายเป็นประจักษ์พยานเพียงปากเดียว แต่ผู้เสียหายเบิกความถึงเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นลำดับขั้นตอนตรงไปตรงมาเชื่อมโยงสอดคล้องกัน สอดคล้องกับคำให้การชั้นสอบสวน หลังเกิดเหตุผู้เสียหายเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้นางสาว น. ผู้เป็นมารดาทราบ ซึ่งนางสาว น. ให้การไว้โดยละเอียดในชั้นสอบสวน แม้นางสาว น. เบิกความในชั้นพิจารณาว่า พยานไม่ได้สอบถามรายละเอียด

ละเอียดยจากผู้เสียหายขัดแย้งกับคำให้การชั้นสอบสวน แต่ข้อเท็จจริงได้ความจากรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2563 ซึ่งโจทก์แถลงว่า โจทก์พูดคุยกับผู้เสียหายแล้ว ผู้เสียหายไม่ยินยอมตอบคำถาม ต่อมาผู้เสียหายแถลงต่อศาลชั้นต้นว่า ก่อนวันดังกล่าว 1 วัน นางสาว น. บอกผู้เสียหายว่า นางสาว น. จะพาผู้เสียหายไปศาล หากมีใครถาม ไม่ให้ผู้เสียหายพูดอะไร และเช้าวันสืบพยาน นางสาว น. บอกย้ำกับผู้เสียหายอีกหลายครั้งว่าไม่ให้ผู้เสียหายตอบคำถามใด ๆ พฤติการณ์ดังกล่าวทำให้น่าเชื่อว่านางสาว น. ช่วยเหลือจำเลยให้พ้นผิดและคำให้การชั้นสอบสวนของนางสาว น. เป็นความจริงยิ่งกว่าคำเบิกความในชั้นพิจารณา คำเบิกความของนางสาว น. จึงไม่มีผลทำให้คำเบิกความของผู้เสียหายมีน้ำหนักลดน้อยลงหรือไม่น่าเชื่อถือ ประกอบกับผู้เสียหายให้การต่อพนักงานสอบสวนในโอกาสแรกที่พนักงานสอบสวนสามารถดำเนินการได้ซึ่งเป็นเวลาที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์และพนักงานสอบสวนถามปากคำของผู้เสียหายโดยมีพนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะห์ และนางสาว น. ผู้เป็นมารดาเข้าร่วมการสอบปากคำดังกล่าวด้วย ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ผู้เสียหายสามารถให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสมบูรณ์แก่พนักงานสอบสวน แล้วผู้เสียหายยังนำชี้สถานที่เกิดเหตุให้พนักงานสอบสวนจัดทำบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญา แผนที่สังเขปแสดงสถานที่เกิดเหตุ ภาพถ่ายประกอบการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และภาพถ่ายประกอบคดี สอดคล้องกับคำเบิกความและคำให้การชั้นสอบสวนของผู้เสียหายอีกด้วย เชื่อว่าผู้เสียหายให้การชั้นสอบสวนตามความเป็นจริงที่ได้ประสมมาโดยปราศจากมูลเหตุจูงใจ แม้คำเบิกความของผู้เสียหายแตกต่างจากคำให้การชั้นสอบสวนอยู่บ้างก็เป็นเพียงพลความ ไม่ทำให้คำเบิกความของผู้เสียหายมีน้ำหนักลดน้อยลงหรือไม่น่าเชื่อถือ และแม้พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของโจทก์ไม่พบตัวอสุจิและส่วนประกอบของน้ำอสุจิในช่องคลอดของผู้เสียหาย อีกทั้งพนักงานสอบสวนไม่ได้ยึดที่นอนและผ้าปูที่นอนไปตรวจหาคราบอสุจิ แต่ผู้เสียหายไม่ใช่เด็กเร่ร่อนหรือส่าสอนทางเพศ หากไม่เป็นความจริงผู้

เสียหายคงไม่กล้าบอกเล่าให้นางสาว น. ผู้เป็นมารดาทราบ ให้การต่อพนักงานสอบสวนโดยมีพนักงานอัยการ นักสังคมสงเคราะห์ และมารดาเข้าร่วมฟังการสอบปากคำด้วยแล้วยังเบิกความต่อศาลยืนยันข้อเท็จจริงเหมือนเดิม เพราะเป็นเรื่องที่น่าอับอายและเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหาย และไม่ได้คิดว่าผู้เสียหายถูกเลียมสอนให้ปรักรปรำจำเลย แม้ผู้เสียหายไม่ได้บอกเล่าให้ผู้อื่นทราบข้อเท็จจริงในระยะเวลาที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ ซึ่งอาจจะเป็นพิรุณอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขนาดที่จะทำให้คำเบิกความของผู้เสียหายมีน้ำหนักลดน้อยลงไปหรือไม่น่าเชื่อถือ อีกทั้งในการสืบพยานศาลชั้นต้นซักถามผู้เสียหายผ่านนักจิตวิทยาซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและความเชี่ยวชาญในการซักถามเด็กอันเป็นวิธีพิจารณาคดีสำหรับพยานที่เป็นเด็กเป็นการเฉพาะต่างจากพยานบุคคลทั่วไป ย่อมทำให้ผู้เสียหายสามารถให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องสมบูรณ์แก่ศาล ไม่ปรากฏว่าผู้เสียหายมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเหตุระแวงสงสัยว่าผู้เสียหายกำลังปรักรปรำจำเลยให้ต้องรับโทษหนักเช่นนี้ เชื่อว่าผู้เสียหายเบิกความไปตามความเป็นจริงที่ได้ประสบมาโดยปราศจากมูลเหตุจูงใจ ส่วนที่ผู้เสียหายไม่ได้เบิกความว่าจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหายเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลากลางวันด้วยนั้น เห็นว่า ตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2563 ศาลชั้นต้นบันทึกว่า ศาลชั้นต้นให้โจทก์นำส่งบันทึกภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหายที่บันทึกไว้ในชั้นสอบสวน แล้วจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหายดังกล่าวให้คู่ความฟัง แล้วจึงเริ่มสืบพยานโจทก์ปากผู้เสียหาย ดังนั้น แม้ผู้เสียหายไม่ได้เบิกความถึงการกระทำของจำเลยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลากลางวัน แต่เมื่อศาลชั้นต้นจัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหาย ซึ่งพนักงานสอบสวนจัดให้มีการบันทึกไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 133 ทวิ วรรคสี่ ให้คู่ความฟังแล้ว จึงต้องถือสื่อภาพและเสียงคำให้การของผู้เสียหายเป็นส่วนหนึ่งของคำเบิกความของผู้เสียหายในชั้นพิจารณาของศาล ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา 172 ตี วรรคสาม เมื่อสื่อภาพและเสียงทำให้การของผู้เสียหาย  
ดังกล่าวมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของจำเลยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา  
กลางวันแล้ว ต้องถือว่าผู้เสียหายเบิกความถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวในชั้นพิจารณาแล้ว  
ส่วนจำเลยให้การต่อพนักงานสอบสวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยมี  
ทนายความและบุตรสาวร่วมฟังการสอบสวนอยู่ด้วย แต่ไม่ให้การต่อสู้อ้างฐานที่อยู่  
อ้างบุคคล เอกสาร หรือวัตถุเป็นพยานแต่อย่างใด จำเลยเพิ่งอ้างฐานที่อยู่และอ้าง  
บุคคลเป็นพยานเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ภายหลังจากให้การต่อพนักงาน  
สอบสวนครั้งแรกเกือบ 1 เดือน โดยปราศจากเหตุผล ซึ่งเป็นพิรุณ แล้วพยานบุคคล  
ของจำเลยให้การและเบิกความเป็นพยานยืนยันฐานที่อยู่ของจำเลยเฉพาะวันที่ 30  
และวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 วันที่ 1 และวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เท่านั้น ไม่ได้  
ยืนยันฐานที่อยู่วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ด้วย ส่วนการที่จำเลยไม่ได้หลบหนีและ  
เข้ามาขอตัวต่อพนักงานสอบสวน ยังไม่ใช่พยานหลักฐานที่สนับสนุนว่าจำเลยไม่ได้  
กระทำความผิดตามฟ้องข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 และข้อ 1.7 พยานหลักฐานของโจทก์ที่  
นำสืบมารับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยกระทำความผิดฐานกระทำชำเรา  
เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด โดยเด็กนั้น  
จะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 277 วรรคสอง ประกอบ  
มาตรา 285 รวม 6 กรรม พยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลักฐาน  
ของโจทก์ได้ และไม่จำต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผล  
แห่งคดีเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น แต่คดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 และ  
ข้อ 1.7 ว่า จำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายโดยใช้กำลังประทุษร้ายบังคับปลุกปล้ำ  
และจับผู้เสียหายนอนลงบนพื้น ทั้งนี้ โดยจำเลยมีเจตนาจะกระทำชำเราผู้เสียหาย  
แล้วจำเลยกระทำชำเราผู้เสียหาย พฤติการณ์ของจำเลยตามที่โจทก์บรรยายฟ้องดัง  
กล่าวเป็นอาทิปฏิกิริยาที่จำเลยจะกระทำชำเราผู้เสียหายนั่นเอง จะถือว่าจำเลยกระทำ  
อนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด โดย



เด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสาม ประกอบมาตรา 285 อีกบทหนึ่งไม่ได้ แม้จำเลยมิได้ฎีกาในปัญหาข้อนี้ แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เอง และแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคหนึ่ง และมาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215 และมาตรา 225 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 และข้อ 1.7 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสอง ประกอบมาตรา 285 มานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้องทั้ง 6 ข้อดังกล่าว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสาม ประกอบมาตรา 285 อีกบทหนึ่ง มาด้วยนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา แต่ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง โจทก์บรรยายฟ้องข้อ 1.6 ว่า วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลาใกล้ค่ำก่อนเที่ยง จำเลยกระทำอนาจารผู้เสียหายโดยใช้มือจับ ลูบคลำอวัยวะเพศของผู้เสียหาย โดยผู้เสียหายไม่ยินยอม อันเป็นการกระทำแก่ผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วยประการอื่นใด แล้วศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดดังกล่าว ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง ประกอบมาตรา 285 แต่ศาลชั้นต้นปรับบทลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสาม ประกอบมาตรา 285 ซึ่งไม่ถูกต้องแม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาในปัญหาข้อนี้ แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้เองและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 215 และมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยตามฟ้องข้อ 1.6 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคสอง ประกอบมาตรา 285 และให้ยกฟ้อง

ความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นผู้อยู่ภายใต้อำนาจด้วย  
ประการอื่นใดโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็ก  
นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรค  
สาม ประกอบมาตรา 285 ตามฟ้องข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.5 และข้อ 1.7 ส่วนโทษและ  
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7

(กิตติพงษ์ ศิริโรจน์-ประเสริฐ เสียงสุทธีวงศ์-อนันต์ วงศ์ประภารัตน์)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายคณองเดช สวัสดิ์วงศ์วิชา

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายประสิทธิ์ ตันติเสรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ.2599/2563

ต้น

หมายเหตุ